

1508751-19.2019.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... elemento de convicção foi apresentado.

É certo que, na sentença do processo n. 1500109-40/2019 (crime de tráfico), o juízo deliberou que, do total apreendido (R\$ 11.550,00 + R\$ 422,00), fosse mantido em depósito o montante de R\$ 4.500,00.

Tratou-se, no entanto, de mera providência cautelar, a fim de resguardar eventual direito do ofendido Sebastião, a ser analisado em ação cível ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508751-19.2019.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508751-19.2019.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria,
Portaria - 2095688/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2533056 - CENTRAL
POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2095688 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2095688 - CENTRAL
POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2095688 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2095688 - CENTRAL
POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2095688 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS BITTENCOURT SILVA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

LUCAS BITTENCOURT SILVA e ANDRÉ LUIS PINHEIRO SANTANA foram dados como incurso nas penas do art. 171, §4º, do Código Penal, porque, no dia 29 de janeiro de 2019, por volta das 20h30, no interior do Shopping Boulevard, nesta cidade, em unidade de designios entre eles, mediante meio fraudulento, obtiveram vantagem ilícita, no valor de R\$ 6.520,00, em prejuízo da vítima Sebastião Roberto Caldas, pessoa com idade superior a sessenta anos.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 16 de abril de 2021 (fls. 382/383). O réu Lucas foi citado (fls. 394) e apresentou a defesa preliminar de fls. 404/405.

Citado por edital (fls. 428/429), o corréu André apresentou a defesa preliminar de fls. 412/421, alegando que ocorreu a decadência, pois não sobreveio representação da vítima dentro do prazo legal.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e testemunhas e os réus foram interrogados (fls. 517 e 524 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 528/532).

A defesa técnica do réu André Luís se manifestou a fls. 548/558, alegando que: 1)- como tinha dívida com Lucas, este pediu a André para somente buscar um cartão e lhe entregar; 2)- apenas foi até à casa da vítima, pegou o cartão e entregou para Lucas; 3)- André não fez ligações para a vítima e nem usou o cartão dela; 4)- não foi observado o prazo previsto no artigo 38, parágrafo único, do Código de Processo Penal; 5)- a fls. 168 do feito n. 4844-13/2019, o juízo intimou os advogados constituídos pela vítima para que, no prazo de dez dias, manifestassem-se sobre o pedido de arquivamento, fls. 169; 6)- passado o prazo, não houve manifestação da vítima; 7)- no processo n. 3751-15/2019, nota-se que o intuito da vítima era apenas o ressarcimento de seu prejuízo; 8)- a fls. 269/270, a vítima se manifestou apenas pedindo a restituição do valor que foi retirado de sua conta; 8)- mesmo a vítima sendo advogado e tendo vários advogados, teve que ser intimado várias vezes pelo escrivão Rafael para apresentar representação; 9)- mesmo alertada pelo escrivão Rafael sobre o prazo de representação, a vítima compareceu sozinha, sem seus patronos, depois de dois dias, isto é, em 26/08/2020, fora do prazo para representar, fls. 285, e ainda tinha dúvida quanto à representação; 10)- não foi comprovado o dolo específico de causar prejuízo para terceiro; 11)- somente foi "arrolado no caso" porque fez uma ligação para o celular de Lucas com a intenção de convidá-lo para ir até seu hotel e, no momento, o celular de Lucas estava com o policial Abel; 12)- no celular de André, que foi submetido a perícia em outro processo, nada foi detectado, sequer uma mensagem trocada com Lucas, não se podendo falar em concurso de pessoas. Pediu a absolvição e, alternativamente, a fixação da pena no mínimo e o estabelecimento do regime inicial aberto.

O réu Lucas apresentou as alegações finais de fls. 579/583, alegando que: 1)- a confissão restou isolada; 2)- as provas são frágeis; 3)- deve ser afastada a causa de aumento de pena, já que ausente consciência do acusado de que a vítima era sexagenária. Pediu a absolvição e, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação retroativa da Lei 14.155/21 e a fixação de regime inicial diverso do fechado, com observância do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 26/32, pelo auto de apreensão de fls. 36 (um cartão bancário do banco Caixa Econômica Federal em nome da vítima, em poder do acusado Lucas; dois mil e doze reais em poder de Lucas; um crachá azul escrito "Caixa Econômica Federal" em nome de "João Carlos Ribeiro" e com a foto de André, acompanhado por documento "termo de entrega e responsabilidade retirada de documentos"; R\$ 422,00 em poder de André; um cartão bancário em nome de Giulia Pontes Ribeiro; um cartão bancário em nome de Luiz A Cordeiro em poder do réu André; R\$ 11.550,00 no quarto do hotel onde hospedados André e Giulia; um crachá do Banco do Brasil em nome do réu André; uma pasta transparente contendo notas fiscais, comprovantes de depósitos, comprovantes de transferência de valores e "termos de entrega e responsabilidade - retirada de documentos", alguns em branco e outros preenchidos de modo manuscrito, nos nomes de Sebastião Roberto Caldas, Simone Maria de Souza Silva, Luiz Aparecido Cordeiro e Osvaldo Pacheco; 5 CRLVs do mesmo veículo de placas FTP - 2949; um telefone celular Motorola XT 1920-19 em poder de Lucas, em bom estado de conservação; um telefone celular novo, modelo S9 Samsung, na caixa lacrada e acompanhado por sacola da loja Samsung, no interior do veículo apreendido; um telefone celular, marca Samsung, em regular estado de conservação, com chip Vivo, em poder de Giulia; um telefone celular em péssimo estado de conservação, com chip Vivo, em poder do réu André; três telefones celulares Samsung Galaxy J8, novos, em caixas fechadas e com acessórios de fábrica

(dois deles com a caixa aberta), no quarto de hotel onde hospedados o réu André e Giulia; um telefone celular Motorola moto Z 3 play, em caixa respectiva, novo, com acessórios de fábrica, localizado no mesmo quarto de hotel) e pelo auto de reconhecimento de fls. 240.

A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída aos acusados.

Em juízo, a vítima Sebastião Roberto Caldas exibiu documento demonstrando sua data de nascimento. Recebeu um telefonema informando que seu cartão teria sido usado para efetuar compra nas Lojas Americanas do Bauru Shopping, tratando-se de fraude. Após, recebeu novo telefonema, em que o interlocutor informava ser funcionário do banco, dizia que seu cartão havia sido clonado e que deveria entregá-lo a outro funcionário da mesma instituição financeira, o qual passaria em sua casa identificado com o crachá do banco. Pediram-lhe que ligassem para o "0800" do cartão. Segundo a polícia lhe explicou, tal telefonema foi destinado a uma moça de nome Giulia. Ela fez toda a orientação do que deveria fazer, com uma oratória muito boa. Mora num residencial fechado e assumiu o risco. Pensou que, se fosse golpe, ao menos identificaria a pessoa que entraria no residencial, pois a câmera iria gravar a placa do carro dela e filmá-la. Entregou seu cartão ao indivíduo que se identificou como funcionário do banco, o réu André. Havia passado a senha para aquela moça, por telefone. Passado algum tempo, começou a receber mensagens de transações com seu cartão. Verificou que uma delas ocorreu no shopping com seu genro e sua filha. Avisou a polícia militar e a segurança do shopping. Entrou uma loja onde havia ocorrido a última compra. Deram-lhe a descrição de Lucas. A moça da loja apontou de longe de quem se tratava. Junto com seu genro, abordou Lucas. A polícia já estava ao lado. Lucas estava em posse de seu cartão. Os celulares por ele adquiridos estavam num carro. Era o mesmo veículo com o qual André foi em sua casa buscar o cartão. Foram para a delegacia de polícia. Ali, conversou bastante com o delegado e sugeriu diligência de encontrar o rapaz que foi em sua casa e a moça com quem falou no telefone. Sobreveio informação de que eles estavam num hotel. A polícia foi ao hotel e os deteve. Passou a senha no momento em que ele próprio, Sebastião, telefonou para o "0800" do banco, número que constava do verso do cartão. Quem atendeu, parece, foi a moça de nome Giulia. No shopping, a polícia conversou com Lucas e recuperou seu cartão. Não sabe se Lucas estava em posse de dinheiro na ocasião. Ele indicou um carro que estava estacionado no shopping. No automóvel, foram encontrados celulares. Tratava-se de aparelhos novos, a par de outros dois que eram de uso deles. Os aparelhos novos foram os adquiridos com seu cartão. Tentou acordo com a polícia, no sentido de receber os celulares, devolvê-los à loja e cancelar as transações do cartão. Na audiência de instrução, consegue reconhecer André, pois tem a foto dele que foi tirada pela câmera de segurança do condomínio. Não consegue reconhecer Lucas. Na foto que tem, André está de lado. Confessa que ficou com um pouco de dificuldade, mas tudo leva a crer que é ele. Na data do fato, viu André na delegacia e teve certeza tratar-se do indivíduo que foi em seu residencial para pegar o cartão. Na oportunidade, entregou-lhe o cartão pessoalmente. Ele estava identificado com o crachá da Caixa Econômica Federal. Chegou a conversar com André quando da entrega do cartão. Sofreu prejuízo. Lucas foi quem fez as compras. Foi intimado para comparecer à delegacia e oferecer representação apenas uma vez. Houve a apreensão de R\$ 6.520,00 que lhe pertenciam, referentes a envios de TED e saques administrativos. Quer ter esse montante restituído. Soube que, com os réus, foi apreendido elevado valor em dinheiro. Atendeu todas as convocações da polícia, sendo que a última, inclusive, foi feita através de um telefonema pelo escrivão Rafael. A partir do momento em que soube da necessidade da representação, compareceu na delegacia no mesmo dia e a ofertou. A testemunha Renato Augusto Magalhães, policial militar, afirmou ter recebido solicitação para apoiar diligência na qual um indivíduo fazia compras no shopping com cartão de terceiro. No local, o indivíduo detido confessou informalmente o delito e indicou duas outras pessoas que participavam da empreitada criminoso. Tais pessoas foram detidas em um hotel. Não se lembra se conversou diretamente com o indivíduo abordado no shopping. Ele estava na posse do cartão da vítima. Salvo engano, os funcionários do shopping acionaram a polícia. Não se lembra como o réu ali presente foi identificado como o suspeito do delito. Também não se se recorda

se o acusado estava de carro e o que teria sido encontrado no veículo. Os policiais Abel e Nosor chegaram antes no shopping. O réu Lucas foi quem indicou as outras duas pessoas, disse que fazia as compras a mando delas e indicou-lhes o paradeiro. Enquanto Lucas era conduzido até a delegacia, foi com seu colega a um hotel na rua Primeiro de Agosto. Os outros dois suspeitos estavam sentados, do lado de fora do hotel. Foi localizado um cartão. Os indivíduos se passavam por funcionários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil e, por isso, usavam o cartão. Eles se passavam por funcionários dos bancos, ligavam para os correntistas e faziam com que eles entregassem os cartões com as senhas. De posse de tais elementos, os réus faziam as compras. O réu André também confessou informalmente e na delegacia o envolvimento com o crime.

A testemunha Abel Rodrigues da Silva, também policial militar, informou ter ido ao shopping e se deparado com o solicitante, acompanhado dos vigilantes do estabelecimento. O movimento do suspeito havia sido captado pelo sistema de monitoramento. Abordou-o. Com ele, havia dinheiro e cartão. O acusado, de pronto, confessou que aplicava golpe com o cartão da vítima. Ele indicou um casal que participava da prática do crime, mencionando o hotel onde o casal estava e respectivo endereço. Não foi ao hotel. Outra equipe da polícia foi quem ali esteve. No veículo do indivíduo detido no shopping, havia dois celulares que ele havia comprado com o cartão da vítima. As compras, salvo engano, foram feitas nas lojas Samsung e Casas Bahia. Não se lembra se esteve nessas lojas. O cartão da vítima estava com o réu abordado no shopping.

A testemunha Allan Michel Caldas Silva disse que é genro da vítima Sebastião. Foi com Sebastião ao Shopping e acionaram a polícia. No shopping, conseguiram identificar o suspeito e abordá-lo. A polícia o prendeu. Ele estava na posse do cartão de seu sogro e, no carro dele, havia celulares. Foi na loja da Samsung. Ali, os funcionários lhe disseram que o réu havia feito a compra e lhe passaram a descrição dele. Alguém da loja também indicou quem era o suspeito. Apareceu notícia de compra feita com o cartão bancário de seu sogro no celular deste.

Interrogado em juízo, o réu André Luis exerceu seu direito ao silêncio.

Interrogado em juízo, o corréu Lucas declarou que, ao encontrar André, já tinha algo específico que havia feito sem a participação dele. Pediu-lhe que fosse buscar um cartão em local que era de conhecimento dele (de Lucas). Acabou ocorrendo de ambos serem detidos. Quem iria concluir "isso" seria ele, Lucas. Precisava de alguém que fosse buscar o cartão e colocou André para realizar a tarefa. Não é o mentor do golpe. Havia mais gente envolvida. Como a vítima disse, havia outras pessoas na ligação, mas tais pessoas estavam em local distante. Pediu a André apenas que fosse buscar o cartão num dado endereço, para ganharem um dinheiro juntos. Todavia, não lhe explicou especificamente do que se tratava. Acredita que André não soubesse que se cuidava de um golpe. Não teve contato com a vítima pessoalmente. Apenas sabia o endereço onde estava tal cartão. Pessoas de outra cidade ligavam para o ofendido. Ao invés de ir buscar o cartão, pediu a André para que o fizesse.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação dos acusados pelo crime de estelionato, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

Inicialmente, não vinga a tese de que não houve representação dentro do prazo legal.

Conforme já decidido por este juízo a fls. 300/303:

"A Lei n. 13964/2019 foi publicada em 24/12/2019 e, conforme estabelecido em seu artigo 20, entrou em vigor trinta dias depois, ou seja, em 23/01/2020. O fato ora apurado ocorreu em 29/01/2019, ou seja, data anterior à vigência da lei nova.

A vítima foi intimada para ofertar representação em 24/08/2020 (fls. 281) e o fez em 26 de agosto de 2020 (fls. 282).

Assim, na falta de previsão legal, por analogia, deve-se aplicar o artigo 91 da Lei 9.099/95, intimando-se a vítima para que, no prazo de 30 dias, ofereça representação.

Logo, somente deve ser reconhecida a decadência ao final do decurso do referido prazo, desde que ausente manifestação do ofendido.

Aplica-se a "ratio" do seguinte julgado do

Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACOTE ANTICRIME. LEI N. 13.964/2019. § 5º DO ART. 171 DO CP. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO COMO REGRA. NOVA LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. ART. 5º, XL, DA CF. APLICAÇÃO DO ART. 91 DA LEI N. 9.099/1995 POR ANALOGIA.

1. As normas que disciplinam a ação penal, mesmo aquelas constantes do Código de Processo Penal, são de natureza mista, regidas pelos cânones da retroatividade e da ultratividade benéficas, pois disciplinam o exercício da pretensão punitiva.

2. O processo penal tutela dois direitos de natureza pública: tanto os direitos fundamentais do acusado, voltados para a liberdade, quanto a pretensão punitiva. Não interessa ao Estado punir inocentes, tampouco absolver culpados, embora essa última solução se afigure menos danosa.

3. Não é possível conferir a essa norma, que inseriu condição de procedibilidade, um efeito de extinção de punibilidade, quando claramente o legislador não o pretendeu.

4. A retroação do § 5º do art. 171 do Código Penal alcança todos os processos em curso, ainda sem trânsito em julgado, sendo que essa não gera a extinção da punibilidade automática dos processos em curso, nos quais a vítima não tenha se manifestado favoravelmente à persecução penal. Aplicação do art. 91 da Lei n. 9.099/1995 por analogia.

5. O ato jurídico perfeito e a retroatividade da lei penal mais benéfica são direitos fundamentais de primeira geração, previstos nos incisos XXXVI e XL do art. 5º da Constituição Federal. Por se tratarem de direitos de origem liberal, concebidos no contexto das revoluções liberais, voltam-se ao Estado como limitadores de poder, impondo deveres de omissão, com o fim de garantir esferas de autonomia e de liberdade individual. Considerar o recebimento da denúncia como ato jurídico perfeito inverteria a natureza dos direitos fundamentais, visto que equivaleria a permitir que o Estado invocasse uma garantia fundamental frente a um cidadão.

6. Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar, para determinar a aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, devendo ser a vítima intimada para manifestar interesse na continuação da persecução penal em 30 dias, sob pena de decadência, em aplicação analógica do art. 91 da Lei n. 9.099/1995. (HC 583.837/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). (o grifo não é do original). Embora este juízo venha entendendo que, nos processos com denúncia já recebida, não há necessidade de representação da vítima, a razão de decidir do precedente supra merece aqui aplicação. Dito de outro modo: estando o feito na fase de inquérito, deve a vítima ser intimada para, na forma do art. 91 da Lei n. 9.099/95, aplicado por analogia, ofertar ou não representação no prazo de trinta dias.

No caso, como visto, logo que foi intimada a vítima, compareceu na delegacia e ofertou representação dentro do prazo legal.

Desta forma, não há que se falar no arquivamento do feito."

Acresça-se não haver razão para alteração do decidido, uma vez que nenhum fato ou fundamento novo foi trazido pela defesa.

Com efeito, embora se tenha alegado que a vítima foi intimada pelo escrivão Rafael para comparecer à delegacia de polícia por várias vezes e tenha deixado escoar o prazo decadencial, nenhuma prova foi feita nesse sentido.

Afasta-se, pois, a alegação de decadência.

Quanto ao tema de fundo, a ação penal é procedente.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

O réu Lucas confessou a prática do crime em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a condenação, mesmo porque nada indica tenha sido o réu insincero ao se autoincriminar.

Nesse sentido:

"Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário." (TJSP, RT 744/573). De qualquer forma, a confissão de Lucas não está isolada no conjunto probatório, mas sim corroborada pelos depoimentos insuspeitos da vítima, de seu genro Allan Michel e de dois policiais militares.

Com efeito, segundo a prova oral, André foi quem se dirigiu à residência da vítima e dela recebeu o cartão bancário, ao passo que uma mulher obteve os dados da respectiva senha, enquanto Lucas foi ao shopping - com o mesmo veículo utilizado pelo primeiro para ir até o ofendido - e adquiriu celulares usando cartão e senha alheios e obtidos fraudulentamente.

Observe-se que, no veículo em questão, foram apreendidos os celulares que Lucas houvera acabado de adquirir com o cartão do ofendido.

Em que pese Lucas ter dito, em seu interrogatório, que não informou claramente a André sobre o golpe, seria no mínimo ingênuo aceitar que este último não soubesse que estava participando da fraude.

Afinal, André foi até à casa de terceiro munido de um crachá que o identificava como funcionário da Caixa Econômica Federal, mesma instituição financeira responsável pela emissão do cartão que foi buscar.

Corroborando tal dedução, Lucas admitiu ter informado a André que, por meio do ato que praticaria (buscar o cartão da vítima), iriam ganhar um dinheiro.

Como alguém poderia acreditar que conseguiria dinheiro lícito apenas indo buscar um simples cartão na residência de terceiro ?

É certo inexistir prova de que foi André quem manteve contato prévio com a vítima, como também é certo que não foi ele quem fez uso do cartão e senha obtidos fraudulentamente para adquirir bens e realizar saques.

Nada obstante, quando se tem um crime praticado em coautoria e de forma organizada, os comparsas se dividem na realização das funções necessárias à obtenção do resultado visado por todos eles.

Assim é que a conduta de André, consistente em ir buscar o cartão da vítima, foi peça importante e indispensável para se atingir a finalidade buscada pelo grupo criminoso.

Na mesma linha de raciocínio, não há que se falar em ausência de dolo no comportamento de André.

Como bem explicita a doutrina, a conduta dolosa é caracterizada pela consciência e vontade de praticar o fato típico.

No caso, o réu André agiu com consciência e vontade de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante emprego de fraude.

Afinal, ele aceitou a proposta de Lucas, e foi buscar o cartão da vítima na casa dela, sabendo que o item em questão seria utilizado para finalidade ilícita visando obtenção de vantagem financeira.

Tanto André tinha plena consciência de que se tratava de um golpe que se apresentou diante do ofendido como funcionário do banco Caixa Econômica Federal, estando inclusive na posse de um crachá que o identificava como tal.

Em suma, a condenação de ambos os réus pelo crime de estelionato é medida de justiça.

Passa-se à aplicação das penas, iniciando-se por Lucas.

O réu Lucas é reincidente (fls. 364 - art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal; e fls. 364/365 - art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal).

No entanto, confessou amplamente a prática do crime.

Entende o juízo que a atenuante da confissão, por dizer respeito à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

"Por envolver a personalidade dos agentes, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante e deve ser compensada com a agravante da reincidência."

(HC n. 288.910/SP, 6ª Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. Em

21/10/2014) (em TJSP, Apelação n. 0020654-38.2013.8.26.0071, j. 21/05/2015).

No caso concreto, no entanto, não se pode determinar pura e simplesmente a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, pois, como visto, esta última é ensejada por duas condenações anteriores.

Nessa ótica, o melhor a fazer é desconsiderar apenas parcialmente o efeito das condenações pretéritas.

Nesse sentido:

"... não há como se operar a compensação integral ante a constatação de múltiplas reincidências. A melhor solução para a hipótese, a fim de não desprestigiar a confissão proporcionada pelos réus, é desconsiderar uma das condenações que caracterizam a reincidência e acrescer à pena patamar de aumento somente pelas condenações restantes." (TJSP, Apelação n. 0023777-06.2010.8.26.0344, rel. Salles Abreu, j. 28/02/2012).

Sendo assim, na segunda fase de aplicação da pena, considerando a reincidência e sua parcial compensação com a atenuante da confissão, eleva-se a pena na proporção de apenas um sexto, resultando em um ano e dois meses de reclusão, mais onze dias-multa.

Quanto à causa de aumento de pena do art. 171, §4º, do Código Penal, não deve incidir no caso em tela.

Apesar de a vítima ser pessoa sexagenária, não restou comprovado com a necessária certeza que os réus tinham conhecimento de tal circunstância.

Cabe ressaltar que eles apenas tiveram contato breve com o ofendido: André apenas esteve na presença dele para buscar seu cartão bancário, ao passo que Lucas nem ao menos o viu.

A tudo some-se que, quando da prática criminosa, a vítima contava com sessenta e um anos de idade (fls. 17), a reforçar a conclusão de que os agentes poderiam não saber se tratar de pessoa idosa.

Assim, pairando dúvida sobre tal circunstância, a causa de aumento em apreço deve ser afastada.

Enfim, não havendo outras modificadoras, para Lucas são definitivas as penas de um ano e dois meses de reclusão, mais onze dias-multa.

Por se tratar de agente reincidente, com duas condenações anteriores por crimes de roubo majorado, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

O disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não tem repercussão na redefinição do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que, conforme certidão de fls. 366, o réu cumpre pena por outro processo.

Logo, eventual regime diverso somente pode ser fixado pelo Juízo das Execuções Criminais, após somatório das reprimendas ainda a cumprir.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Fixa-se a pena, doravante, para o corréu André.

Ele deve ser considerado sem antecedentes criminais.

Isto porque a condenação noticiada na certidão de fls. 362/363 (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), embora com trânsito em julgado, refere-se a fato cometido no mesmo dia do apurado nestes autos.

Não se pode falar, pois, em condenação definitiva por fato anterior mas com trânsito em julgado ocorrido posteriormente à prática de nova infração penal (situação que ensejaria reconhecimento de mau antecedente).

Sendo assim, fixa-se a pena de André no mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão, mais dez dias-multa.

Não havendo modificadoras, essas penas são as definitivas.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente a ação, para: 1)- condenar o réu Lucas Bittencourt Silva como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, a cumprir um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar onze dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo; 2)-

condenar André Luis Pinheiro Santana como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, a cumprir um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar dez dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada.

Oportunamente, anotem-se as condenações no sistema informatizado.

A vítima, quando ouvida em juízo, formulou requerimento para restituição de valor em dinheiro.

No feito n. 3751-15/2019, o ofendido Sebastião solicitou a devolução do numerário.

No feito n. 6077-45/2019, fls. 46, o juízo determinou que os interessados (vítima Sebastião e réu André) recorressem à via cível, com fundamento no § 4o do artigo 120 do Código de Processo Penal.

Como se vê, o juízo já deu solução definitiva, no âmbito criminal, para a questão do numerário que permanece depositado nos autos.

Não se tratou de apenas determinar que se aguardasse a apuração cabal dos fatos no processo penal, para depois decidir a controvérsia na sentença.

Logo, nada há para ser deliberado a respeito, mormente se se considerar que nenhum novo elemento de convicção foi apresentado.

É certo que, na sentença do processo n. 1500109-40/2019 (crime de tráfico), o juízo deliberou que, do total apreendido (R\$ 11.550,00 + R\$ 422,00), fosse mantido em depósito o montante de R\$ 4.500,00.

Tratou-se, no entanto, de mera providência cautelar, a fim de resguardar eventual direito do ofendido Sebastião, a ser analisado em ação cível que julgar conveniente propor contra o réu André.

Cabe chamar a atenção para o fato de que, no acórdão de fls. 565/574 do processo n. 1500109-40/2019, o Desembargador Relator entendeu que, mesmo o perdimento do valor de dois mil reais, imposto na sentença de primeiro grau a título de confisco de dinheiro proveniente de tráfico, não se justificava, haja vista que o réu André comprovou ter tal valor origem em atividade diversa e lícita.

Uma razão a mais, pois, para não se deferir desde logo à vítima o numerário cuja restituição pretende.

Em se tratando, como visto, de providência cautelar, a manutenção do valor em dinheiro nestes autos perdurará por trinta dias, a contar da intimação da vítima acerca da presente sentença. Dentro de tal prazo, caso o ofendido não venha a propor a ação cível e a requerer a remessa do numerário depositado nestes autos ao juízo cível, deverá ele ser liberado em favor do réu André, uma vez que o dinheiro foi apreendido em sua posse e, segundo entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, não ficou provado tratar-se de valor oriundo do tráfico.

P.R.I.

Bauru, 29 de março 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA